

0002176-57.2019.8.26.0366

Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA
Comarca: Mongaguá
Foro: Foro de Mongaguá
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 10/11/2022

...

Deixo de valorar negativamente a reincidência para o crime de tráfico de drogas, pois já serviu de critério para o afastamento da causa de diminuição na terceira etapa, evitando-se, assim, o bis in idem.

Por fim, na terceira etapa, elevo a pena do crime de tráfico de 1/5 de acordo com o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, o que arbitro considerando o número de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mongaguá
Foro de Mongaguá
1ª Vara
Avenida São Paulo, 300, Mongaguá (SP) - cep 11730-000

0002176-57.2019.8.26.0366 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:

0002176-57.2019.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEOVANE DA SILVA e outro

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA
Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra GEOVANE DA SILVA, pronunciado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, caput, do Código Penal, na forma tentada (artigo 14, inciso II, do Código Penal), com a pretensa incidência da qualificadora do parágrafo 2º, inciso VII, daquele dispositivo; no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; e no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Sustenta a denúncia que, no dia 26 de junho de 2019, por volta das 16h, na Rua Francisco de Morães, final (matagal), Jardim Itapoã, nesta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado tentou matar o policial civil Roberto Gomes dos Santos Filho, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Sustenta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado trazia consigo e vendia, para fins de tráfico, 32 porções (pinos) de cocaína (com peso aproximado de 29g), 143 porções (pedras) de crack (com peso aproximado de 24g) e 67 porções de maconha (com peso aproximado de 67g), o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar encartados aos autos (fls. 18/19 e 20/21) e fotografia de fls. 36.

Sustenta por fim que, nas mesmas circunstâncias, o acusado portava arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra que policiais civis se dirigiram até o local dos fatos para efetuar

patrulhamento e coibir o tráfico de entorpecentes na região. Após alguns instantes de "campana", em viatura descaracterizada, puderam observar a presença do acusado e outros dois indivíduos, em atitude suspeita. Em dado momento, outro indivíduo, chamado Higor Dias Augusto, saiu do matagal, sendo abordado pela equipe policial com porções de maconha, alegando ser usuário. Neste momento, o acusado e seus comparsas perceberam a abordagem policial e empreenderam fuga, dispensando uma sacola plástica no chão, a qual continha os entorpecentes acima mencionados, embrenhando-se na mata. Enquanto a equipe policial vistoriava o local, os policiais escutaram um barulho na mata, oportunidade em que se esconderam em uma moita e visualizaram o acusado se aproximando, munido de uma arma de fogo. Quando o acusado chegou perto do policial Roberto, este se identificou, oportunidade em que o acusado desferiu 2 tiros em sua direção, não o atingindo vez que o policial se esquivou dos disparos. Ato contínuo, reagindo à injusta agressão, o policial Roberto efetuou três disparos contra o acusado, atingindo-o na lateral do abdômen e nas duas pernas.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 68/72).

Preclusa a decisão de pronúncia de fls. 283/289, mantida pelo Tribunal de Justiça (fls. 348/360), o acusado foi submetido nesta data a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em plenário foram colhidas as declarações do ofendido e os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que o acusado nega a autoria delitiva, dizendo que estava apenas adquirindo droga, tendo comprado duas porções de maconha. Em dado momento, a polícia chegou e já realizou disparos, ouvindo-os e correndo. Percebeu, em seguida, que foi atingido e caiu ao chão. Havia no local além dos dois traficantes mais 5 pessoas, entre elas um conhecido seu. Tinha sido abordado anteriormente pelo policial Alexandre, mas não sabe o motivo da versão dos policiais. Nega ter realizado os disparos, estar traficando ou portando arma. Não conhece Higor.

Nos debates, o Ministério Público pugnou pelo acolhimento da pretensão acusatória, condenando-se o acusado nos exatos termos da pronúncia. Já a defesa técnica foi pela absolvição ante a falta de provas da autoria e inexistência de intuito de matar.

Ato contínuo, o Conselho de Sentença votou a primeira série de quesitos, para o crime de homicídio, respondendo afirmativamente aos 1º e 2º quesitos, confirmando a materialidade e a autoria; negativamente ao 3º quesito, afastando o dolo de matar, prejudicados os demais quesitos e séries.

Certidões de distribuição e folhas de antecedentes estão a fls. 415/419 e 420/423. Fundamentação

De acordo com a resposta aos quesitos pelo Conselho de Sentença, o Tribunal do Júri concluiu que o acusado não agiu com o intuito de matar a vítima, desclassificando a conduta daquela do artigo 121 do Código Penal, razão pela qual passo a proferir sentença, nos moldes do artigo 492, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

Existência e Autoria

A existência e a autoria delitivas restaram parcialmente demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial, através do laudo de fls. 279/282, detectou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína, assim de 143 porções individuais de crack com massa líquida total de 26,3g de cocaína, 32 porções individuais de cocaína com massa líquida total de 8,9g e 67 porções individuais de maconha com massa líquida total de 87,1g.

A própria variedade e quantidade de droga apreendida, bem superior ao que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, corrobora a versão acusatória no sentido de que seu destino não era o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do

agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros), de até 16 pedras de crack (cerca de 5,2g) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto ao crack, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o padrão médio de uso no Brasil de 13,42 porções por dia apurado por pesquisa da FIOCRUZ, idealizada em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Pesquisa Nacional sobre o Uso do Crack, 2014); com o uso de mais de 10 pedras por episódio relatado por 47% de 67 usuários de crack atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010); com o relato de uso de 10 ou mais pedras por 69,5% de 67 usuários de crack atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial de Igrejinha, Taquara e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul (Rogério Lessa Horta et al, Perfil dos usuários de crack que buscam atendimento em Centros de Atenção Psicossocial. Cad. Saúde Pública, v. 27, n. 11, p. 2263-2270, 2011); e com a média de 73,2 pedras de crack por semana encontrada em pesquisa com 72 pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Serra, no Espírito Santo (Janine Andrade Moscon, Avaliação dos padrões de consumo de crack, cognição global e de funções executivas em usuários de ambulatório especializado de alta demanda, Mestrado, UFES, 2013).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga – ainda assim, no caso, a quantidade é realmente expressiva e desborda do consumo pessoal.

Ainda, o laudo pericial de fls. 102/112 atesta ter sido apreendida arma de fogo, em funcionamento e com capacidade vulnerante, recentemente disparada, bem assim a apreensão de 9 cartuchos íntegros.

E a violência empregada contra o policial, a utilização da arma de fogo e a autoria de todas as condutas delitivas também restou comprovada pelos demais elementos probatórios colhidos. Reporto-me, a este respeito, ao teor dos depoimentos das testemunhas já mencionados na decisão de pronúncia e daqueles colhidos em plenário. O laudo pericial de fls. 275/278 indica que o acusado realizou disparo de arma de fogo, daí os resíduos encontrados em sua mão, tendo recebido ele próprio disparos

de arma de fogo que o acertaram e demandaram atendimento médico. Os agentes policiais atestam que, pouco depois de indivíduos responsáveis por um ponto de venda de drogas se evadirem com a chegada da viatura, GEOVANE retornou ao local e realizou os disparos em direção ao policial Roberto, quanto este se identificou. E o usuário-adquirente confirmou que eram três indivíduos no ponto de venda, um deles armado.

A propósito, em fase anterior, Higor Dias Augusto disse que tinha ido a local dos fatos adquirir maconha e quando estava saindo os policiais estavam chegando. Mencionou que eram três os traficantes, sendo que um deles estava armado. Referiu que estava sozinho no local dos fatos, onde também só estavam os traficantes. Disse que um dos traficantes estava na entrada, o outro com a sacola e um terceiro com o dinheiro. Mencionou ter ouvido disparos de arma de fogo, cerca de cinco em sequência. Procedeu ao reconhecimento do acusado em Juízo, de forma, negativa, aduzindo que foi atendido por um traficante e os outros dois estavam mais distantes, deitados no mato. Negou ter sido revistado por algum dos traficantes. Em plenário, a vítima Roberto disse que receberam denúncia de que três rapazes estavam na Biqueira do Cemitério e foram realizar operação com o policial Alexandre e o investigador André. Quando estavam próximos da Biqueira, avistaram três rapazes no mato e um rapaz saindo, que abordaram e identificaram como usuário. No momento desta abordagem os três rapazes do mata saíram correndo, dois de blusa escura e um de blusa azul. Um deles, de blusa escura, arremessou uma sacola preta no mato. Perguntado, o usuário, de nome Higor, disse que havia acabado de comprar dois papalotes de maconha, que exibiu aos policiais. O depoente e Alexandre foram até o mato em direção à sacola, lá encontrando crack, cocaína e maconha em grande quantidade. Ficam por ali procurando outras coisas envolvendo a droga, avistaram mesa e banco em que os traficantes ficaram sentados. Depois de cerca de 5 minutos escutaram um barulho no mato, parecendo ser uma pessoa retornando ao local por uma picada que existia ali. Abrigaram-se atrás de uma moita e esperaram que essa pessoa saísse, para saber se era um dos elementos que tinha corrido. Essa pessoa vinha devagar, com cautela, pisando devagar e esperando. Quando chegou a cerca de 2 ou 3m, aparecendo em sua visão, notou que GEOVANE estava com uma pistola na mão, praticamente apontando em sua direção. Gritou “polícia” e o indivíduo desferiu dois tiros e, na sequência, o depoente deu três tiros. GEOVANE correu com a arma na mão pela picada e, cerca de 10 ou 15m depois, encontrou o indivíduo caído, com a pistola. Era uma pistola .380, Taurus, de numeração raspada, segundo se recorda. Ligaram para o SAMU e, informalmente, GEOVANE disse que tinha a função de segurança, tomando conta da sacola. A testemunha, na Delegacia, disse que tinha acabado de comprar a droga, de dois rapazes, e havia um terceiro indivíduo, de cútis branca, portando uma pistola. Apreenderam a droga e a arma. Normalmente na Biqueira há um campana ou dois, próximos do local, olhando se a polícia ou alguém diferente chega. Neste caso, não havia campanas, mas duas pessoas: o sacola, que segura a droga, e o que tem a função de arrecadar dinheiro – estratégia criminosa para que não percam a droga e o dinheiro, juntos. Além disso, há a função de segurança, que fica com a arma para intimidar policiais e usuários que querem causar. Não conhecia pessoalmente GEOVANE, mas já havia escutado que ele estava dando trabalho na região, se envolvendo em alguma ocorrência, talvez na Praia Grande. A notícia era de que GEOVANE era ladrão, roubava, e parece que foi pego com arma em data anterior. GEOVANE estava com a arma e teve a chance de largar a arma quando gritou “polícia”, mas ele realizou os dois disparos logo em seguida. O local do confronto distava cerca 30-50m da outra viatura, em que estava o investigador e o usuário, em região descampada, com algumas árvores próximas ao local do disparo. Apenas presenciou uma pessoa armada e o usuário também relatou que havia somente uma pessoa armada. Foram apreendidos 9 cartuchos intactos. Quando revidou os tiros, estava de frente com GEOVANE, logo após ele ver o depoente e realizar os disparos. Os tiros foram de contenção, e não no “garrafão” (jargão policial), a uma distância de 3m ou 4m. GEOVANE, depois, foi encontrado cerca de 10 ou 12m, caído na trilha. Não sabiam, de antemão, quem eram os envolvidos na traficância, motivo pelo qual decidiram abordar o usuário também. Os policiais ouviram a aproximação e acertaram de ficar escondidos e aguardando a pessoa do matagal se revelar.

Já a testemunha Alexandre atestou que estava em operação de combate ao tráfico de entorpecentes e foram checar uma denúncia anônima de comércio de drogas na Boca do Cemitério, próximo à área de mata. No local, havia 3 indivíduos efetuando a traficância, rapazes jovens, dois com vestimentas escuras e um com blusa azul. Chegando a cerca de 50m, visualizaram três rapazes próximos à mata e um quarto indivíduo vindo e indo em direção à viatura. Os três indivíduos batiam com as características e decidiram abordar o quarto indivíduo que saía, de forma discreta. Ele estava portando duas porções de maconha. Contudo, os outros 3 rapazes, a cerca de 20m, perceberam a abordagem e se evadiram. Um deles, dispensou, inclusive, uma sacola na trilha. O investigador André ficou com o usuário e foi junto com o policial Roberto verificar o local, localizando a sacola com droga (143 de crack, 167 porções de maconha e 32 de cocaína). Fizeram varredura no local para ver se encontraram mais alguma coisa. Passaram 5 ou 10 minutos e ouviram o que parecia ser alguém caminhando no mato, indo a seu encontro. Decidiram ficar abaixados e abordar quem fosse. Roberto estava mais próximo, a cerca de 3m a sua frente, e visualizou o policial se levantando, apresentando como policial e, logo em seguida, foram realizados dois disparos. Roberto conseguiu se desvencilhar e revidou, com três tiros. Deram a volta e o rapaz estava caído cerca de 10 ou 15m a frente. Estava com a pistola, segurando, e tinha sido baleado na perna e no abdômen. Chamaram o SAMU. Informalmente, GEOVANE, de blusa azul, disse que estava fazendo a segurança no local e trabalhando no tráfico, com a função de abordar usuários e revidar caso a polícia chegasse, sendo a função de venda e arrecadação do dinheiro dos demais. Conversaram com o usuário, que confirmou que o rapaz de azul estava armado e abordava o pessoal, pedindo que levantasse a camisa. Conduziu, então, todos e tudo à Delegacia. Não conhecia GEOVANE e, porque fez pesquisas sobre os dados, verificou que ele tem passagem por roubo, porte de arma, em Praia Grande. Estima que a viatura distava 50m do local da fuga dos rapazes, havendo mais 10m até o local em que faziam as buscas, o local do confronto. Foram realizados cinco disparos, dois por parte de GEOVANE e três por Rodrigo, frente a frente, primeiro os do acusado e, depois, os do policial, um olhando para o outro. Apurou que apenas GEOVANE estava armado no local e o depoente não realizou disparos. GEOVANE portava apenas o armamento e segurava a pistola na mão. Abordaram o usuário para que ele, vendo a movimentação dos policiais, não avisasse os traficantes e frustrasse a diligência. Fizeram as buscas sem fazer muito barulho. Rodrigo ouviu a aproximação de alguém e acertaram de ficar escondidos e aguardando a pessoa do matagal se revelar. A propósito do valor do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, realmente, ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos. Em outras palavras, o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos do que a palavra dos agentes policiais (v. *mutatis mutandis* HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), o que está presente no caso concreto consoante os demais elementos de prova já valorados. Conforme a lição de Aury Lopes Jr., “não há que se falar em restrição ao depoimento dos policiais. Eles podem depor sobre os fatos que presenciaram e/ou dos quais têm conhecimento, sem qualquer impedimento. Obviamente, deverá o juiz ter muita cautela na valoração desses depoimentos, na medida em que os policiais estão naturalmente contaminados pela atuação que tiveram na repressão e apuração do fato. Além dos prejulgamentos e da imensa carga de fatores psicológicos associados à atividade desenvolvida, é evidente que o envolvimento do policial com a investigação (e prisões) gera a necessidade de justificar e legitimar os atos (e eventuais abusos) praticados. Assim, não há uma restrição ou proibição de que o policial seja ouvido como testemunha, senão que deverá o juiz ter muita cautela no momento de valorar esse depoimento. A restrição não é em relação à possibilidade de depor, mas sim ao momento de (des)valorar esse depoimento.” (Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529). No caso, a narrativa policial está em consonância com os demais elementos de prova,

em especial os achados periciais, em especial nas mãos de GEOVANE, e o depoimento de terceira testemunha.

A versão defensiva, assim, restou de todo isolada, nada indicando estivesse ali para adquirir droga e que os agentes policiais tivessem inventado toda a cena dos disparos contra si realizados.

Acrescente-se que, embora não tenha sido o acusado encontrado em poder da droga, o seu retorno ao local do crime – em que deixada a sacola, afinal apreendida –, empregando violência e com arma de fogo, bem indica sua adesão e participação na venda que pouco antes se realizava. Tal o que, frise-se, foi mesmo atestado por Higor, no sentido de que havia um indivíduo de “segurança” do tráfico.

Enfim, nestes termos, restaram confirmadas as teses de fato da acusação a respeito da lesão corporal e “não há elementos de prova que tornem viável ter ocorrido fato concreto diverso de qualquer proposição fática que integre a imputação.” (Gustavo Badaró, Epistemologia Judiciária e Prova Penal, RT, 2019, p. 259).

Adequação Típica

Afastado pelo Conselho de Sentença o dolo de matar o policial, extraído do quadro probatório que o acusado agiu com o intuito de evitar a ação policial, de apreensão da droga e prisão dos responsáveis pelo comércio espúrio, empregando efetiva violência, assim caracterizando a figura do artigo 329 do Código Penal.

Do mesmo modo, a prova evidenciou que o acusado praticou, de forma consciente e deliberada, a conduta de vender drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistindo sua participação na segurança, com a arma de fogo, da empreitada, assim nos exatos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

Contudo, não vislumbro do conjunto probatório a prática da conduta autônoma de portar a arma de fogo, mas tão somente no contexto da prática do crime de drogas. Daí porque, nos termos do artigo 383, caput, do Código de Processo Penal, acolho em parte a pretensão acusatória e atribuo qualificação jurídica diversa à denúncia para reconhecer a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06.

No mais, prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Uma vez que o acusado é reincidente, é inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, não exigindo a lei que a reincidência seja específica para afastar o redutor.

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, no procedimento trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal, na medida em que necessária e suficiente à retribuição e à prevenção especial.

Na primeira etapa (artigo 59, incisos I e II, do Código Penal), aprecio as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis a partir da pena média, a fim de atender o princípio da isonomia do artigo 5º, caput, da Constituição Federal, pois “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador. Esse é um ponto estratégico na individualização da pena, justamente para evitar a nociva padronização. A quem merece pena superior ao mínimo, deve o juiz saber aplicá-la, por uma questão de justiça.” (Guilherme de Souza Nucci, Curso de Direito Penal, v. 1, 3ª ed., 2019, Cap. XXXII, item 3.1, p. 1020). Do contrário, dar-se-ia idêntico tratamento para condutas de distinta reprovabilidade quando presentes exclusivamente circunstâncias judiciais favoráveis.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. O acusado não ostenta Maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência

(artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social do acusado, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade do acusado, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, *Fermin Ramírez vs. Guatemala*, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias dos crimes não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa. De se ressaltar, particularmente quanto ao crime de resistência, que a oposição se deu a execução de ordem de prisão em flagrante, em contexto de comercialização de drogas e com o emprego de violência, inclusive com arma de fogo, mas o que não extrapola a reprovabilidade já adequada à pena intermediária adotada.

As consequências dos crimes são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

O comportamento da vítima, quanto ao crime de resistência, não contribuiu para o delito, cuja censurabilidade não é por isto diminuída. Bem ao contrário, o crime se deu porque o policial cumpria seu dever legal.

Quanto ao crime da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga são importantes e não autorizam um juízo favorável ao acusado, pois superiores ao suprimento mensal de um usuário de droga, mas não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena-base para além da pena intermediária.

Por tudo isto, considero favoráveis a conduta social e neutras as demais circunstâncias judiciais. Não havendo motivo para atribuição de sobrevalor a nenhuma delas, atribuo a cada circunstância favorável e desfavorável peso equivalente a 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato. Contudo, quanto ao crime de drogas, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, atribuo peso equivalente a 1/5 para as circunstâncias relativas à natureza e a quantidade da droga, à personalidade e à conduta social do agente e 1/6 para as demais, tudo sobre o intervalo de pena em abstrato a cada circunstância favorável e desfavorável. A fração é eleita em interpretação sistemática da fração mínima das causas de aumento e diminuição expressas no Código Penal, aplicando-se sobre o intervalo em respeito ao papel do legislador na individualização da pena, de modo que possa alcançar o piso ou o teto legais.

Fixo a pena-base em 8 anos de reclusão (tráfico de drogas) e 9 meses e 10 dias de detenção (resistência).

Na segunda etapa (artigos 61 a 67 do Código Penal), é de rigor o agravamento da pena do crime de resistência por força da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), cuja constitucionalidade já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (RE 453000, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013).

Por conseguinte, observada a preponderância dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, agravo a pena deste crime em 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato.

Deixo de valorar negativamente a reincidência para o crime de tráfico de drogas, pois já serviu de critério para o afastamento da causa de diminuição na terceira etapa, evitando-se, assim, o bis in idem.

Por fim, na terceira etapa, elevo a pena do crime de tráfico de 1/5 de acordo com o artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, o que arbitro considerando o número de

majorantes presentes, mas diante da especial reprovabilidade, no caso vertente, do emprego de arma de fogo com numeração suprimida, a justificar elevação diferenciada.

Assim, fixo a pena privativa de liberdade em 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão (tráfico de drogas) e 1 ano e 1 mês de detenção (resistência).

Quanto à pena pecuniária, a gradação do número de dias-multa deve observar rigorosamente o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal, conforme tudo o que já se expôs.

Assim, correspondendo a pena-base a 800 dias-multa, fixo a pena de multa final em 960 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa, nos moldes do art. 49, § 1º, do CP, em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Regime inicial

Deixo de promover a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Em razão da reincidência e da condenação a pena de reclusão superior a 8 anos, fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal.

Para a pena de detenção, o regime inicial será o semiaberto, ante a sistemática que lhe é própria (artigo 33, caput, do Código Penal).

Substituição e sursis

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da quantidade de pena aplicada por crime doloso, não preenchido o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Também não cabe a suspensão condicional da pena, fixada em mais de 4 anos, assim independentemente da idade do acusado ou de razões de saúde (artigo 77, caput e parágrafo 2º, do Código Penal).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para condenar GEOVANE DA SILVA às penas somadas, em concurso material (artigo 69), de reclusão de 9 anos, 7 meses e 6 dias, em regime inicial fechado, e a 960 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, do mesmo diploma; e de detenção de 1 ano e 1 mês, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do artigo 329, caput, do Código Penal.

Prisão preventiva

Nos termos do artigo 387, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, aprecio e mantenho a prisão preventiva. Mantida a prisão durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível à preservação da ordem pública e à aplicação da lei penal, e ora confirmada, com a condenação, a imputação por crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tais requisitos subsistema de forma ainda mais nítida.

Assim, recomendo o acusado à prisão. Expeça-se a guia de recolhimento provisória (art. 8º da Res. CNJ 113/2010).

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Comunique-se à vítima (artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal); ao condenado em

regime inicial fechado, expeça-se o mandado de prisão, se o caso, e a guia de recolhimento definitiva (artigo 674 do Código de Processo Penal e da Resolução CNJ 113/2010); ao condenado em regime inicial semiaberto, expeça-se o mandado de prisão, se já estiver preso, e a guia de recolhimento definitiva e encaminhe-se ao juízo da execução competente (Resolução CNJ 474/22 e Comunicado CG 628/22); ao condenado em regime inicial aberto, intime-se para comparecimento à audiência admonitória, se estiver em liberdade, e expeça-se o mandado de prisão específico (Comunicado CG 1356/16).

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Também após o trânsito em julgado, atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso; expeça-se a competente certidão para execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa).

Comunicado o ajuizamento da execução da multa (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou verificada a prescrição da pretensão executória (evento 22), arquivem-se os autos com a movimentação 61619 no SAJ.

Int.

Mongaguá, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA